

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

A R R E S T

**nr. 184.598 van 24 juni 2008
in de zaak A. 132.794/XII-3768.**

In zake : de NV SIEMENS ATEA, thans de NV SIEMENS,
die woonplaats kiest bij
advocaat C. De Wolf,
kantoor houdende te Maarkedal,
Etikhovestraat 6

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van
Binnenlandse Zaken.

tussenkommende partij :

de NV NEXTIRAONE,
die woonplaats kiest bij
advocaat D. D'Hooghe,
kantoor houdende te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25.

D E R A A D V A N S T A T E, X I I e K A M E R,

Gezien het verzoekschrift dat de NV Siemens Atea, thans de NV Siemens, op 7 februari 2003 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van “de beslissing van onbekende datum van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, [...] en die delegatie heeft verleend aan de Federale Politie, Algemene Directie van de Materiële Middelen, Directie van de Aankoopdienst, [...] om de opdracht betreffende de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van telefoonsystemen ten voordele van de federale politie, zoals opgenomen in het bestek nr. DMA 2002 R3 611 aan Nextiraone nv te gunnen, evenals de daaruit volgende impliciete weigeringsbeslissing om voormelde opdracht niet aan Siemens Atea te gunnen”;

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 15 april 2003;

Gelet op de beschikking van 29 april 2003 die de tussenkomst van de NV Nextiraone toelaat;

Gezien de memories van antwoord en van wederantwoord;

Gezien het verslag opgesteld door eerste auditeur J. Stevens;

Gelet op de beschikking van 9 januari 2007 die de neerlegging ter griffie van het verslag en van het dossier gelast;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen en gezien de laatste memories;

Gelet op de beschikking van 12 december 2007 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 29 januari 2008;

Gehoord het verslag van kamervoorzitter D. Verbiest;

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. De Wolf, die verschijnt voor de verzoekende partij, adviseurs K. Peeters en R. Goossens, die verschijnen voor de verwerende partij, en van advocaat E. De Raeymaecker, die loco advocaat D. D'Hooghe, verschijnt voor de tussenkomende partij;

Gehoord het advies van eerste auditeur J. Stevens;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

OVERWEEGT WAT VOLGT :

1. Betreffende de in het geding zijnde opdracht hebben acht inschrijvers een offerte ingediend, waaronder de verzoekende partij en de tussenkomende partij NV Nextiraone -voorheen NV Alcatel.

2. De verwerende partij heeft slechts uittreksels uit de offertes van de tussenkomende partij en van de verzoekende partij neergelegd. Van haar kant heeft de verzoekende partij al evenmin zelf haar offerte neergelegd.

De verzoekende partij vraagt de Raad van State in een brief van 12 juni 2003 om de verwerende partij te bevelen de volledige offerte van de

tussenkomen de partij neer te leggen. In haar laatste memorie herhaalt zij dat verzoek.

De verwerende partij betoogt in haar laatste memorie dat de overgelegde gegevens toereikend zijn om aan te tonen dat de grieven van de verzoekende partij ongegrond zijn en dat zij “gerechtigd” zou zijn “om zich te beperken tot de mededeling van welbepaalde uittreksels uit de offerte van de tussenkomen de partij”. Zij verwijst voorts naar de artikelen 51 en 80 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de daarin vervatte paragraaf 4 op grond waarvan bepaalde gegevens niet kunnen worden medegedeeld door de aanbestedende overheid aan de in paragraaf 1 bedoelde inschrijvers, indien openbaarmaking van die gegevens schade zou kunnen toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen dan wel indien de eerlijke mededinging tussen de leveranciers of dienstverleners daardoor zou kunnen worden aangetast.

De tussenkomen de partij is zoals de verwerende partij van oordeel dat het neergelegde administratief dossier toereikend is om alle grieven van de verzoekende partij te onderzoeken en verwijst eveneens naar de in de voornoemde artikelen 51 en 80 vervatte verplichtingen.

3. De verzoekende partij stelt in haar voormelde brief dat zij door de beperking van dossierstukken haar middelen niet nader kan uitwerken en het haar onmogelijk wordt gemaakt nieuwe middelen aan te voeren.

4. De verwerende en de tussenkomen de partij beroepen zich te dezen ten onrechte op de voornoemde artikelen 51 en 80 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, teneinde een beperkte overlegging van het administratief dossier te verantwoorden.

Tegen die opvatting verzetten zich de artikelen 21, derde en vierde lid en 21 bis, §1, zevende en achtste lid, van de gecoördineerde wetten van de Raad van State en artikel 6, §2, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Krachtens die bepalingen -zoals recentelijk ook gesteld in het arrest van de Raad van State nr. 176.826 van 14 november 2007 inzake Betonac- dient de

verwerende partij of de overheid die er in het bezit van is, het volledige administratief dossier neer te leggen, dat het geheel van de stukken bevat op grond waarvan zij zich heeft gesteund om haar beslissing te nemen en mag zij zich niet het recht voorbehouden om te kiezen welke stukken zullen worden onderworpen aan het tegensprekelijk debat. Dit administratief dossier moet bestaan op het ogenblik dat de bestreden beslissing wordt genomen die een van de laatste stukken van dat dossier vormt. Het kan niet worden aangenomen dat dit dossier op de een of andere manier wordt gewijzigd ten gevolge van en wegens het beroep dat voor de Raad van State is ingesteld. Het dient integraal te worden bezorgd aan de griffie terzelfdertijd met de memorie van antwoord. Het is niet geoorloofd dat de verwerende partij een selectie in de stukken maakt die het administratief dossier vormen, welke ook de criteria zijn voor die selectie, en dat op die wijze wordt beslist over hetgeen nuttig is voor de Raad van State om de rechtmatigheid van de bestreden beslissing te beoordelen.

Het vertrouwelijk karakter van sommige stukken van het administratief dossier dat verband houdt met het zakengeheim, in zoverre het is aangetoond en erkend door de Raad van State, stelt op geen enkele wijze de verwerende partij vrij van haar verplichting om het gehele administratief dossier aan de Raad van State voor te leggen. Die neerlegging van dat dossier is voorgeschreven door de regelgeving met als doel het de rechter mogelijk te maken te beslissen op grond van een zo nauwkeurig mogelijke kennis van de feitelijke omstandigheden en de juridische motieven die hebben geleid tot de totstandkoming van de bestreden beslissing.

Te dezen blijkt dat de verwerende partij niet het gehele administratief dossier heeft neergelegd. Er is reden toe om haar daartoe te verplichten. Ook de offertes van de verzoekende en van de tussenkomenende partijen zullen aldus met dat dossier worden neergelegd.

5. Vervolgens rijst de vraag wat de Raad van State te doen staat met de stukken die door partijen als vertrouwelijk worden aangemerkt.

In dat verband zijn de artikelen 21 en 23 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State relevant : zij voorzien beide in de mogelijkheid dat de Raad van State zich alle stukken van een administratief dossier doet voorleggen. Betreffende die artikelen stelde de Raad van State bij arrest nr. 164.028 van

24 oktober 2006 inzake NV Varec, aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag :

“Schenden de artikelen 21 en 23 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, in die zin geïnterpreteerd dat de vertrouwelijke stukken van een dossier van de administratie aan het administratief dossier moeten worden toegevoegd en aan de partijen moeten worden medegedeeld, artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, aangezien zij het niet mogelijk maken het recht op de eerbiediging van het zakengeheim te verzekeren ?”

In zijn arrest nr. 118/2007 van 19 september 2007 heeft het Grondwettelijk Hof op die prejudiciële vraag geantwoord, dat het recht op de eerbiediging van het privé-leven in zekere mate ook toekomt aan de rechtspersonen en dit recht de bescherming van hun zakengeheimen omvat. Betreffende de verhouding tussen het recht op een eerlijk proces en de bescherming van het privé-leven stelde het Hof :

“[...]

B.8.2. In die zin geïnterpreteerd dat ze de tegenpartij geenszins in staat stellen het vertrouwelijke karakter van bepaalde stukken in het administratief dossier aan te voeren teneinde de mededeling ervan aan de andere partijen te verhinderen, zijn de in het geding zijnde bepalingen niet bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

B.8.3. In die interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord.

B.9.1. Het Hof stelt echter vast dat de in het geding zijnde bepalingen een andere interpretatie kunnen krijgen.

B.9.2. Ofschoon het recht op een eerlijk proces wordt geschonden wanneer documenten die essentieel zijn voor de oplossing van het geschil, niet worden meegedeeld aan één van de partijen in het geding (EHRM, 25 januari 1995, *Mc Michael, Verenigd Koninkrijk*, § 80), moet dat principe wijken wanneer de strikte toepassing daarvan een kennelijke schending zou teweegbrengen van het recht op de eerbiediging van het privéleven van sommige personen, door hen een bijzonder ernstig en zeer moeilijk te herstellen risico te laten lopen (HvJ, 11 december 1985, *Hillegom t. Hiltenius*, C-110/84, § 33; HvJ, 24 juni 1986, *Akzo Chemie t. Commissie*, C-53/85, § 28, HvJ, 6 april 1995, *BPB Industries en British Gypsum t. Commissie*, C-310/93, §§ 26 en 27; HvJ, 13 juli 2006, *Mobistar*, C-438/04, §§ 40 en 43; zie ook *mutatis mexandis*, EHRM, 20 december 2001, *P.S. t. Duitsland*, §§ 27-30, EHRM, 10 november 2005, *Bocos-Cuesta t. Nederland*, §§ 70-72).

B.9.3. In die gevallen kunnen elementen die beslissend zijn voor de oplossing van het geschil, worden onttrokken aan de tegenspraak van de partijen voor zover de ernstige handicap die daaruit voor sommigen onder hen voortvloeit, door de procedure zoveel mogelijk wordt gecompenseerd.

Daarom moeten de partijen ervan op de hoogte worden gebracht dat er vertrouwelijke stukken bestaan en, indien mogelijk, in staat zijn een

niet-vertrouwelijke versie van die stukken te raadplegen. Bovendien betaamt het dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter het aangevoerde vertrouwelijke karakter van die stukken kan controleren alsmede het feit of ze juist en relevant zijn.

B.9.4. Het staat aan de Raad van State het aangevoerde vertrouwelijke karakter van sommige stukken van het administratief dossier te beoordelen door in elk geval de vereisten van het eerlijk proces en die van het zakengeheim met elkaar af te wegen.

B.10. In die interpretatie dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord”.

Met hetzelfde voormelde arrest nr. 164.028 stelde de Raad van State aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de volgende prejudiciële vraag :

“Moet artikel 1, [lid] 1, van richtlijn 89/665 [...] juncto artikel 15, [lid] 2, van richtlijn 93/36 [...] en artikel 6 van richtlijn 2004/18 [...], aldus worden uitgelegd dat de beroepsinstantie in de zin van dit artikel de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van de zakengeheimen in de door de betrokken partijen -waaronder de aanbestedende dienst- aan haar overgelegde dossier moet garanderen, terwijl zijzelf van deze inlichtingen kennis mag nemen en ze in haar beschouwing mag betrekken?”.

De uitlegging die het Hof van Justitie gaf in zijn arrest van 14 februari 2008 in de zaak gekend onder C-450/06, luidde :

“dat de voor de beroepsprocedures verantwoordelijke instantie in de zin van voornoemd artikel 1, lid 1, de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen moet waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat in de door de betrokken partijen, in het bijzonder door de aanbestedende dienst, aan haar overgelegde dossier, ook al kan zijzelf van deze informatie kennis nemen en deze in haar beschouwing betrekken. Het staat aan deze instantie om te oordelen in welke mate en op welke wijze de vertrouwelijkheid en het geheime karakter van deze informatie moet worden gewaarborgd, rekening houdend met de vereisten van een effectieve rechtsbescherming en van de eerbiediging van het recht van verweer van de procespartijen en, in het geval van een beroep bij een rechter of bij een instantie die een gerecht is in de zin van artikel 234 EG, met het vereiste dat de procedure op alle onderdelen het recht op een eerlijk proces eerbiedigt”.

6. In de lijn van de aangehaalde rechtspraak is het te dezen aan de Raad van State om het aangevoerde vertrouwelijke karakter van de betrokken stukken van het administratief dossier te beoordelen en daarbij de vereisten van het eerlijk proces en die van het zakengeheim met elkaar af te wegen.

Gelet op de techniciteit van de betrokken materie is de Raad van State evenwel niet bij machte om zonder deskundig advies te beslissen over de vraag

of de stukken die als vertrouwelijk worden aangemerkt, dat ook werkelijk zijn en of ze aan tegenspraak van de partijen moeten worden onderworpen of daar juist moeten aan worden onttrokken.

Daarom moet een deskundige worden aangesteld om de betrokken stukken op het vlak van hun vertrouwelijk karakter, in de context van de betrokken markt, te onderzoeken.

**OM DIE REDENEN
BESLIST DE RAAD VAN STATE :**

Artikel 1.

De debatten worden heropend.

Artikel 2.

De verwerende partij wordt bevolen het gehele administratief dossier neer te leggen, onder meer de offertes van de verzoekende en de tussenkomenende partij bevattend, tevens onder mededeling van een inventaris van de stukken die zij of de inschrijvers als vertrouwelijk aanmerkt en niet de opgave van een van de redenen voor die precieze vertrouwelijkheid, dit binnen de maand van de betekening van huidig arrest.

Artikel 3.

Wordt aangesteld als deskundige : David Stevens, research coördinator ICRI-KU Leuven, gevestigd te Leuven, Sint-Michiëlstraat 6, met als opdracht na kennis genomen te hebben van het gehele dossier aan de kamer zijn beredeneerd standpunt te geven over de vraag, of de inzage van de als vertrouwelijk aangemerkte stukken schade zou kunnen toebrengen aan de commerciële belangen van de betrokken partijen, in voorkomend geval onderscheid te maken tussen de stukken in hun geheel of gedeelten ervan die hij zal aanduiden.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op vierentwintig juni 2008, door de XIIe kamer, die was samengesteld uit :

de HH. D. VERBIEST,

J. LUST,

G. VAN HAEGENDOREN,

Mevr. S. DOMS,

kamervoorzitter,

staatsraad,

staatsraad,

griffier.

De griffier,

De voorzitter,

S. DOMS.

D. VERBIEST.